

1500039-18.2020.8.26.0067

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... droga com ele. O local é conhecido pelo tráfico de drogas. O declarante chegou em Borborema em 2016 e nos poucos períodos em que fica preso pratica o tráfico de drogas. O réu disse que as drogas eram para uso pessoal, mas todos sabem que é praticado tráfico no local. Todas as pessoas que estavam na frente da casa são conhecidas como usuárias de drogas". A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Vara Única

Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, ., Centro - CEP 14955-000, Fone: (16) 3266-1010, Borborema-SP - E-mail: borborema@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO PROCESSO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500039-18.2020.8.26.0067

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Data e horário da audiência

22 de novembro de 2022, 15:30h

Juiz(a)

BRENO COLA ALTOÉ

Promotor(a)

JOSÉ FRANCISCO FERRARI JÚNIOR

Defensor

287893/SP - NATÁLIA REGINA BOTIGELLI

Denunciado:

JUNIOR BARAUNA DA SILVA

Vítima:

Em 22 de novembro de 2022, às 15:30h, sala virtual do Microsoft Teams da Vara Única, do Foro de Borborema, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022, através de videoconferência criada no software "Microsoft Teams" foi aberta a audiência virtual de instrução e julgamento autos da ação entre as partes em epígrafe, ficando consignado que as partes foram intimadas via e-mail, sendo anexado o link de acesso à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, constatou-se a presença virtual do(a) DD Representante do Ministério Público, Exmo(a) Sr(a). Dr(a) JOSE FRANCISCO FERRARI JÚNIOR, do(s) réu(s) JUNIOR BARAUNA DA SILVA e de seu(s) advogado(s) Dr(a). NATÁLIA REGINA BOTIGELLI OAB 287893/SP e da(s) testemunha(s) BRUNO HENRIQUE PEREIRA ULIAN, FELIPE FARIA SIQUEIRA e PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA LOPES.

Ausente(s) a(s) testemunha(s) ELISEU HENRIQUE PRATES DA SILVA, não localizado pelo Oficial de Justiça (fl. 342), bem como HIGOR RODRIGUES DA SILVA, embora devidamente intimado (fl. 318).

Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: Em complemento ao despacho de fls. 230/234, recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, com fulcro na regra do art. 56 da lei 11.343/2006, em face de Junior Baraúna da Silva, a quem se imputa(m) a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A seguir, antes da oitiva da(s) testemunha(s) abaixo qualificada(s), através de transmissão pelo sistema TEAMS, todas foram inquiridas quanto à qualificação constante dos autos, que restou confirmada. Ademais, foram analisados os recintos em que prestariam depoimento constatando que se encontram incomunicáveis.

PM BRUNO HENRIQUE PEREIRA ULIAN, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG 47.954.648-SP, CPF 376.747.048-90, pai Izaías Ulian, mãe Maria de Fátima Pereira Ulian, nascido em 06/07/1991, natural de Lins-SP, Rua Dr. Valentim Gentil, 07, Telefone: (17) 3266-1314, Centro - CEP 14955-000, Borborema-SP
FELIPE FARIA SIQUEIRA, Brasileiro, Policial Militar, RUA DR. FLAVIO PINHEIRO, 55, TERRA BRANCA - CEP 14940-250, Ibitinga-SP
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA LOPES, Brasileiro, Solteiro, Pedreiro, RG 2947669, CPF 039.036.081-30, mãe MARIA ZILMA ALVES FERREIRA, nascido em 23/12/1994, de cor Pardo, natural de Brasília-DF, RUA FRANCISCO MAIANE, 1205 - CEP 14955-000, Borborema-SP

Pelo Ministério Público e Defesa foi dito que desistem da(s) testemunha(s) ELISEU HENRIQUE PRATES DA SILVA e HIGOR RODRIGUES DA SILVA, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

Após, concedido o(a)(s) réu(s) a oportunidade de se entrevistar(em) prévia e reservadamente com seu(s) defensor(es), confirmou(ram) sua(s) qualificação(ões): JUNIOR BARAUNA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 62234109, pai SERGIO BARAUNA DA SILVA, mãe SANDRA MARA RAMOS DO PRADO DA SILVA, Nascido/Nascida 23/03/1998. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Taiuva - Estrada Municipal TAV-227 (a 257 metros do retorno da Rodovia Brigadeiro Faria), SP 326 Km 359 + 600m, Taiuva - CEP 14720-000, Taiuva - SP, 016 32476262. Endereço: RUA MARIA HERMONEGES MARTINS MOURÃO, 65, RUA MARIA HERMONEGES MARTINS MOURÃO, CEP 14955-000, Borborema - SP.

A seguir, o(s) réu(s) foi(ram) interrogado(s), após entrevista reservada com seu(s) advogado(s), sendo realizadas pelo(a) magistrado(a) as advertências legais, inclusive do direito de silêncio.

Indagadas às partes se havia algum requerimento a fazer, responderam que não, o Ministério Público e a Defesa.

Em seguida, o(a) MM. Juiz(a), com a concordância das partes, declarou encerrada a instrução processual, por não haver mais provas a serem produzidas.

Por fim, foi dada a palavra ao Ministério Público, que apresentou alegações finais em forma de memoriais: "JUNIOR BARAÚNA DA SILVA foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/96 (fls. 195/200). em síntese, a inicial narra que: "o denunciado é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e já vinha sendo monitorado pela polícia. Na data dos fatos, JUNIOR vendia e trazia com ele drogas, para fins de tráfico. Assim, alguns usuários se encontravam no portão de sua residência para adquirir drogas. Um deles, adentrou no imóvel e adquiriu 12 (doze) porções de maconha, além de 05 (cinco) porções de cocaína. O usuário iniciava o uso de um cigarro de maconha, que consumiria na companhia d e JUNIOR, no quintal da residência, ocasião em que JUNIOR saiu para atender outros usuários que se encontravam defronte ao imóvel. Nesse momento, a Polícia Militar, que realizava patrulha mento de rotina, passou pelo local, visualizando alguns dos indivíduos que, ao avistá-los, gritaram: "moio", e se dispersaram em seguida, o que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem. O usuário que se encontrava no quintal da residência de JUNIOR empreendeu fuga e, no trajeto, dispensou um

invólucro sobre o telhado da residência localizada à Rua Maria Hermógenes Mourão, n.º 75. Um dos policiais conseguiu abordá-lo, porém, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao retornar para verificar o que ele havia dispensado, o policial encontrou as 12 (doze) porções de maconha, além de 05 (cinco) porções de cocaína, que ele acabara de adquirir. O outro policial adentrou na residência de JUNIOR e, em revista pessoal, encontrou em sua posse 10(dez) porções de maconha. O usuário confirmou que se dirigiu até a residência do denunciado com o fim de adquirir drogas e, na ocasião, fariam uso de um cigarro de maconha” (fls. 195/200). O fato foi praticado em 13 de dezembro de 2019. A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022 (fls. 230/234). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas BRUNO HENRIQUE PEREIRA ULIAN, FELIPE FARIA SIQUEIRA, PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA LOPES, HIGOR RODRIGUES DA SILVA e ELISEU HENRIQUE PRATES DA SILVA. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu. Satisfeito o devido processo legal e encerrada a colheita de provas, verifica-se coeso conjunto probatório, que autoriza a condenação. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/08; registro de informação anônima de fl. 18; laudos de exame químico-toxicológico de fls. 19/20 e fls. 154/155, que atestam a natureza ilícita da substância apreendida; boletim de ocorrência de fls. 36/37, que registra usuário de drogas dizendo que as adquiriu do réu 14 de dezembro de 2019 (fls. 36/37); e pelas provas orais produzidas. A autoria é igualmente inequívoca. Na fase policial, o réu disse que: “o dia dos fatos estava dentro de sua residência quando os Policiais entraram em sua residência. Estava no quintal de sua residência, fumando na maconha na companhia de Paulo. Não sabe onde Paulo mora, o conheceu no facebook. Assim que João Paulo saiu de sua casa ele saiu correndo assim que viu os Policiais. Como os policiais viram João Paulo saindo de sua casa acabaram ingressando em sua residência. Quando os Policiais entraram em sua casa se escondeu embaixo da cama. Os Policiais pegaram a quantia de maconha e cocaína que tinha no bolso. Não sabe dizer a quantia que tinha no bolso. Não sabe dizer se pegaram droga com Paulo. A droga foi comprada na cidade de Novo Horizonte/SP” (fl. 26). Em Juízo, o réu exerceu o direito ao silêncio. A versão do acusado não o isenta da responsabilidade pelo crime cometido. A testemunha BRUNO HENRIQUE PEREIRA ULIAN disse que: “estava mostrando os pontos de tráfico de drogas na cidade para outro policial. O réu é conhecido pelo crime de tráfico de drogas. Passaram na frente da casa dele e havia diversas pessoas na residência. Uma delas gritou moiô, para alertar a chegada da viatura. PAULO HENRIQUE começou a correr e arremessou algo para cima do telhado. Ele invadiu duas casas e foi detido do outro lado do quarteirão. Foi necessário pular três muros para detê-lo. Quando deu a volta no quarteirão, o parceiro do declarante abordou outras pessoas e colocou ao lado da viatura. Retornou até a residência em que ele havia jogado a droga e constatou que se tratava de maconha e cocaína. O parceiro disse que conseguiu abordar JUNIOR e foi encontrada droga com ele. O local é conhecido pelo tráfico de drogas. O declarante chegou em Borborema em 2016 e nos poucos períodos em que fica preso pratica o tráfico de drogas. O réu disse que as drogas eram para uso pessoal, mas todos sabem que é praticado tráfico no local. Todas as pessoas que estavam na frente da casa são conhecidas como usuárias de drogas”. A testemunha FELIPE FARIA SIQUEIRA disse que: “estavam em patrulhamento. Já era de conhecimento do parceiro que havia ponto de tráfico de drogas no local. Alguns metros do local, ouviram o grito “moio”, que é palavra usada nos locais de venda de entorpecentes. Nesse momento, quatro indivíduos saíram correndo. O réu entrou na residência e PAULO saiu em disparada pulando muro para outra casa que dava acesso à rua de trás. O declarante foi ao encalço de JUNIOR. Ele adentrou na residência e se escondeu embaixo da cama. O parceiro policial conseguiu abordar PAULO. JUNIOR foi detido embaixo da cama e com ele havia dez porções de maconha. O colega de farda disse que PAULO dispensou as drogas no telhado da casa ao lado. JUNIOR alegou que as drogas eram para seu uso pessoal. PAULO não admitiu que havia comprado drogas do JUNIOR. Eles alegaram que não se conheciam”. A testemunha PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA LOPES disse que: “que no dia dos fatos foi até a residência de Junior Barauna para comprar droga. Seria a segunda vez que teria ido até a residência de Junior para comprar droga. Quando estava na casa de Junior comprou uma porção de maconha e pediu para Junior enrolar

para usarem. Enquanto estavam no quintal da casa de Junior usando a droga, apareceu duas pessoas no portão da casa de Junior. Os dois seriam um rapaz e uma criança, os quais não conhece. Junior então foi até o portão para atender os dois que haviam chegado. Quando Junior se aproximou do portão conseguiu visualizar um veículo parando na frente da residência de Junior, sendo que Junior voltou correndo pra dentro. Como não conseguiu visualizar qual seria o veículo que estava estacionando e pelo fato de Junior sair correndo, acreditava que seriam pessoas que queriam fazer algo contra Junior, por isso acabou correndo pelos fundos da casa. Ao sair correndo chegou a pular dois muros das residências vizinhas e assim que chegou na rua percebeu que quem estava atrás do declarante seria um policial. Ao perceber que era um policial parou de imediato e passou a obedecer todas as ordens do Policial. Na ocasião foi algemado e encaminhado para o PS local e depois para a base da Polícia Militar. Enquanto estava na Polícia Militar acabou dizendo para os Policiais que tem passagem pela prática de crimes, como o de roubo. Após dizer de seu passado, o Policial Henrique então passou a dizer que o declarante havia dispensado droga durante a fuga. Como o declarante passou a dizer para o Policial que ele estava mentindo, o Policial então ficou mais bravo. Nega que tenha jogado qualquer droga em cima do telhado. Somente esteve na casa do Junior para comprar as drogas". (fl. 27). Em Juízo, disse que: "foi lá comprar drogas. É a segunda vez que foi comprar drogas de JUNIOR. Foi lá comprar drogas e perguntou se podia fumar ali mesmo. JUNIOR concordou e prepararam para fumar um cigarro de maconha ali. Então, alguém chamou e o réu saiu para ver quem era. Então, ele voltou correndo e dizendo que 'moiô'. O declarante não sabia quem estava entrando e por isso correu também. Foi preso por um policial. Havia comprado uma porção de maconha por R\$ 10,00. Ficou sabendo que JUNIOR vendida drogas na casa porque passou ali na frente e viu movimento. Conheceu um rapaz que é usuário que indicou o local ". A testemunha ELISEU HENRIQUE PRATES DA SILVA, ouvida apenas na fase policial, disse que: "informa o declarante que é usuário de drogas. Que a droga que estava com o declarante e localizada pela polícia era para seu consumo próprio. Que teria comprado a droga, no mesmo dia da abordagem Policial, com a pessoa de "Baraúna". "Baraúna" estava vendendo a droga atrás da base do corpo de Bombeiros" (fl. 38). É certo que as declarações tomadas apenas em sede policial podem ser utilizadas para a formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em Juízo. É o que se passa no caso em apreço. As palavras dos policiais e o testemunho de PAULO HENRIQUE, confirmado em Juízo, corrobora integralmente o quanto foi narrado pela testemunha ELISEU somente na fase policial. Ademais, a prática do tráfico de drogas é corroborada registro de informação anônima de fl. 18, recebido poucos dias antes dos fatos, que relata movimentação de usuários na frente da residência. Em reforço, o boletim de ocorrência de fls. 36/37 registra usuário de drogas dizendo que as adquiriu do réu em 14 de dezembro de 2019. Diante do seguro conjunto probatório, o Ministério Público requer a condenação. Em sede de dosimetria, postula-se a majoração da pena-base, dada a diversidade e quantidade de drogas apreendidas com o réu, consistentes em 33,30 g(trinta e três gramas e trinta centigramas) de Cannabis Sativa .L, totalizando 22 (vinte e duas) porções de maconha, e 1,43 g (um grama e quarenta e três centigramas) de cocaína, acondicionada em 05 (cinco) invólucros plásticos. Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (autos n.º 0000898-50.2016.8.26.0067 - fl. 329). Na etapa final, salienta-se que não é cabível a redutora prevista no artigo 33, 4º, da Lei n.º 11.343/06, porque as informações anônimas e o histórico criminal dão conta de que o réu é pessoa que se dedica ao tráfico de drogas há bastante tempo. Postula-se a fixação do regime inicial fechado, vedando-se quaisquer substituições e "sursis". Ante o exposto, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando-se o réu nos termos explanados".

Na sequência, dada a palavra à Defesa, que apresentou alegações finais em forma de memoriais: "MM. Juiz, consta da denúncia (fls. 198/200) que, no dia 13 de Dezembro de 2019, por volta das 21h15m, na Rua Hermógenes Martins Mourão, 65, nesta cidade de Borborema, o Acusado, vendia e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 33,30 g de Cannabis Sativa e 1,43 g de cocaína, acondicionada em 05

invólucros plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo os policiais militares, em patrulhamento pelo local, avistaram indivíduos que, ao visualizá-los, teriam gritado moio, fato este que teria motivado a abordagem. Suposto usuário que se encontrava na residência do Acusado empreendeu fuga e, no trajeto, dispensou um invólucro sobre o telhado da residência vizinha. Por seu turno, o outro policial ADENTROU na residência do ora Acusado e, em revista pessoal, encontrou em sua posse 10 (dez) porções de maconha. Por tal razão, o Acusado foi denunciado por, em tese, praticar o delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE - Invasão de domicílio Impraticável é a continuação do presente sem que seja suscitada a nulidade absoluta do feito, em virtude de violação grave à garantia constitucional insculpida no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, eis que tanto a prisão quanto a suposta apreensão dos entorpecentes ocorreram em situação manifestamente arbitrária. Consta nos depoimentos, de ambos os policiais e condutores da ocorrência, que encontravam-se em patrulhamento pela Rua Maria Hermogenes Mourão, quando um indivíduo teria gritado "moio", motivo pelo qual teriam abordado o Acusado DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA. Ocorre, Excelência, data vênua ao trabalho desempenhado pelos policiais militares, não se pode negar a flagrante inconstitucionalidade da Ação perpetrada pelos agentes. Destaquemos, pois, o que assevera o artigo 5º, XI, da Constituição Federal: Art. 5. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Verifica-se da leitura do dispositivo supra que, para que a entrada no domicílio do indivíduo seja Constitucional, esta deve ocorrer após o CONSENTIMENTO do morador, ressalvadas exceções. No presente caso, a situação não era de flagrância, tampouco os policiais ostentavam mandado de prisão ou de busca e apreensão capazes de estear a entrada, conforme bem salientado no próprio Boletim de Ocorrência anexado às fls. 04/06. Ainda, é de se ressaltar que os Policiais invadiram a residência do Acusado em período noturno Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, que a ação, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial. A decisão proferida pelo ínclito Min. Rel. Nefi Cordeiro, assim dispôs: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ATUAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2. A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente RAFAEL AUGUSTO NUNES. (HC 611.918/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).Grifei. - Da prova ilícita Como é cediço, o direito à prova não é absoluto, apresentando limitações, seja em relação ao objeto da prova, seja em relação ao meio de produção. Nossa Constituição, em seu artigo 5º, LVI, determina que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito no processo penal. No mesmo sentido caminha o Código Processual Penal, em seu artigo 157, que testifica a inadmissibilidade de tais provas, bem como a necessidade de seu desentranhamento do processo. Para fins processuais penais, as provas ilícitas são aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. No caso em apreço, a prova é absolutamente ilícita, eis que oriunda de invasão de domicílio, de tal modo que caminha de encontro aos preceitos constitucionais, ferindo garantias fundamentais. A lesão repelida por

nosso ordenamento jurídico pátrio torna a prova trazida aos autos indigna de estear uma condenação e deve, inquestionavelmente, gerar a absolvição do Acusado. O acima explicitado encontra amparo em recente entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que arregimenta a lúcida posição de que a prova oriunda de invasão de domicílio por mera suspeita é nula. É por todo o exposto que o não reconhecimento de nulidade flagrante no feito implica no deslinde de um processo criminal fora dos padrões e ditames constitucionais. A prova obtida de maneira ilícita, sendo a única amealhada aos autos como gênese do crime ao réu imputado, vicia todo o processo, de tal forma que a medida de Justiça é a absolvição. MÉRITO Conforme informações dos autos percebe-se a ausência de qualquer prova que o denunciado tinha a intenção de vender a droga apreendida no local do crime. Em seu interrogatório, o denunciado é categórico ao afirmar que é apenas usuário habitual e jamais se envolveu na mercancia de qualquer entorpecente. Ainda é de se ressaltar que, não foi encontrado junto ao Acusado ou no local, qualquer quantia de dinheiro. Diante da insuficiência das provas, não há como imputar ao denunciado a autoria pela prática de tráfico de drogas, de forma que, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, o juiz deverá absolvê-lo. As provas trazidas aos autos claramente ratificam o envolvimento do denunciado somente como usuário, estando provado que este não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia. Caso não seja este o entendimento do MM. Juízo, torna-se incontestável então a necessidade de aplicação do princípio do *in dubio pro reo*, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação de Tráfico de Drogas, pois o Acusado não foi encontrado em atividade de traficância. Destarte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que pudessem imputar a prática delituosa ao denunciado, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que fora a conduta do denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente. Ainda, caso Vossa Excelência não vislumbre a *absolvição*, requer que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06. PEDIDOS Por todo o exposto, requer seja reconhecida a nulidade da prova obtida por meio ilícito, em virtude de violação de domicílio, ferindo integralmente o comando constitucional, de tal forma que, por consequência, a absolvição do réu se impõe como medida da mais cristalina Justiça. Na remota hipótese de não ser este o entendimento de Vossa Excelência, requer, subsidiariamente, a absolvição do Acusado, face ao princípio *in dubio pro reo*. Por fim, pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do artigo 28, da Lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o Acusado é usuário de drogas. Pede Deferimento".

A seguir, o(a) MM Juiz(a) deliberou:

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JUNIOR BARAUNA DA SILVA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei 11.343/96, porque no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 21h15min, na Rua Maria Hermógenes Martins Mourão, n.º 65, Centro, nesta cidade e Comarca de Borborema, vendia e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 33,30 g (trinta e três gramas e trinta centigramas) de Cannabis Sativa .L, totalizando 22 (vinte e duas) porções de maconha, e 1,43 g (um grama e quarenta e três centigramas) de cocaína, acondicionada em 05 (cinco) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo toxicológico de fls. 19/20 e 154/155).

Segundo consta na denúncia:

Consoante se apurou, o denunciado é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e já vinha sendo monitorado pela polícia. Na data dos fatos, JUNIOR vendia e trazia com ele drogas, para fins de tráfico. Assim, alguns usuários se encontravam no portão de sua residência para adquirir drogas. Um deles, adentrou no imóvel e adquiriu 12 (doze) porções de maconha, além de 05 (cinco) porções de cocaína. O usuário iniciava o uso de um cigarro de maconha, que consumiria na

companhia de JUNIOR, no quintal da residência, ocasião em que JUNIOR saiu para atender outros usuários que se encontravam defronte ao imóvel. Nesse momento, a Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina, passou pelo local, visualizando alguns dos indivíduos que, ao avistá-los, gritaram: “moiô”, e se dispersaram em seguida, o que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem. O usuário que se encontrava no quintal da residência de JUNIOR empreendeu fuga e, no trajeto, dispensou um invólucro sobre o telhado da residência localizada à Rua Maria Hermógenes Mourão, n.º 75. Um dos policiais conseguiu abordá-lo, porém, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao retornar para verificar o que ele havia dispensado, o policial encontrou as 12 (doze) porções de maconha, além de 05 (cinco) porções de cocaína, que ele acabara de adquirir. O outro policial adentrou na residência de JUNIOR e, em revista pessoal, encontrou em sua posse 10(dez) porções de maconha. O usuário confirmou que se dirigiu até a residência do denunciado com o fim de adquirir drogas e, na ocasião, fariam uso de um cigarro de maconha. Indagado, JUNIOR disse ser usuário de entorpecentes.

Oferecida a denúncia (fls.198/200), o réu foi notificado (fls. 211) e apresentou sua defesa prévia (fls.219/220).

Na fase instrutória, foram ouvidas três testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/96.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha BRUNO HENRIQUE PEREIRA ULIAN, policial militar, disse que estavam em patrulhamento em locais conhecidos por tráfico de drogas quando passaram pela rua do réu, que já era conhecido por isso, e viram diversos indivíduos na frente da residência dele e um gritou “moiô”. O Paulo Henrique era recente na cidade e correu, na fuga dispensou algo, mas foi detido. O parceiro na residência deteve as outras pessoas e disse que o Junior correu mas foi pego. Recuperaram o que foi dispensado pelo Paulo Henrique, era cocaína e maconha, com o Junior também foi encontrado entorpecente. Já havia várias informações sobre o envolvimento dele com o tráfico. O parceiro do depoente disse que o Júnior alegou que era para uso próprio. O Paulo Henrique negou tudo. O que motivou a suspeita é a informação de que a residência era ponto de tráfico, por terem vários usuários na frente da residência e por conta da fuga. Os usuários no local eram o Maicon e os irmãos Eric, Henrique e outro que não recorda o nome, os três menores, e mais uma menina.

A testemunha FELIPE FARIA SIQUEIRA, policial militar, disse que estavam em patrulhamento no local, porque o parceiro já tinha conhecimento de ser local de tráfico, quando ouviram o grito “moiô” e viram quatro indivíduos saindo correndo, sendo que o Junior entrou na residência e o Paulo pulando a residência para outra casa. Como estava na função de motorista, desceu primeiro e foi no encalço do Junior Barauna, que estava na residência escondido debaixo da cama. O parceiro deteve o outro indivíduo na outra rua em residência de terceiro. Com o Junior o depoente encontrou dez porções de maconha. O parceiro voltou com o outro indivíduo e informou que ele tinha dispensado um objeto no telhado de uma casa ao lado, verificaram e encontraram maconha e cocaína. O Junior alegou no local que era para uso pessoal, só fizeram busca pessoal nele, ele foi detido na casa e levado para fora, as porções de maconha estavam com ele. O Junior e o Paulo alegaram que não se conheciam. Só foi apreendida a droga.

A testemunha PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA LOPES, disse que no dia foi na casa do Junior para consumir droga, comprou dele, foi a segunda vez que comprou droga dele, não sabe se ele vendia outras drogas além de maconha e cocaína. Ele deixou fumarem

no local e alguém o chamou no portão e ele foi atender, então ouviu o grito “moiô” e viu ele correndo de volta para dentro, por isso correu também sem saber que eram os policiais. Comprou só uma porção de maconha dele, por R\$10,00. Estava em Borborema por volta de 6 meses. Ficou sabendo que o Junior vendia droga por comentários e porque viu movimento na casa dele. A porção iria ser consumida na mesma área, estava na mão do Junior, não saiu correndo com droga nem sabe sobre droga no telhado. O Junior também é usuário, iriam fumar juntos. Não entrou na casa, estava só na área externa.

A testemunha ELISEU HENRIQUE PRATES DA SILVA, ouvido apenas fase extrajudicial, havia dito que “é usuário de drogas. Que a droga que estava com o declarante e localizada pela polícia era para seu consumo próprio. Que teria comprado a droga, no mesmo dia da abordagem Policial, com a pessoa de “Baraúna”. “Baraúna” estava vendendo a droga atrás da base do corpo de Bombeiros (fl. 38).

Em sede policial, o acusado havia dito que “estava dentro de sua residência quando os Policiais entraram em sua residência. Estava no quintal de sua residência, fumando na maconha na companhia de Paulo. Não sabe onde Paulo mora, o conheceu no facebook. Assim que João Paulo saiu de sua casa ele saiu correndo assim que viu os Policiais. Como os policiais viram João Paulo saindo de sua casa acabaram ingressando em sua residência. Quando os Policiais entraram em sua casa se escondeu embaixo da cama. Os Policiais pegaram a quantia de maconha e cocaína que tinha no bolso. Não sabe dizer a quantia que tinha no bolso. Não sabe dizer se pegaram droga com Paulo. A droga foi comprada na cidade de Novo Horizonte/SP.

Em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Pois bem.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade de domicílio, ressaltando, porém, dentre outras hipóteses, a de flagrante delito.

O caput do artigo 303 do Código de Processo Penal dispõe que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Entende-se crime permanente aquele cuja consumação se prolonga no tempo, como é o caso da modalidade “guardar”, ou, ainda, “ter em depósito” substâncias entorpecentes, aquelas em relação às quais o acusado foi denunciado.

No caso em tela, por se tratar de crime permanente, o réu encontrava-se em estado de flagrância ao ter o seu domicílio invadido pelos guardas municipais.

E, conforme os depoimentos colhidos em juízo, os policiais já tinham conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e havia denúncias anônimas direcionadas ao local (fl. 18), além de terem visualizado usuários conhecidos na frente da residência e o réu ter empreendido fuga, circunstâncias aptas a respaldar a fundada suspeita da prática de tráfico de drogas no domicílio.

Assim, como não houve qualquer desrespeito à norma constitucional, não se pode falar em prova ilícita, de modo que rejeito a preliminar, passando à análise do mérito.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/08; registro de informação anônima de fl. 18; laudos de exame químico-toxicológico de fls. 19/20 e fls. 154/155, que atestam a natureza ilícita da substância apreendida; boletim de ocorrência de fls. 36/37, que registra usuário de drogas dizendo que as adquiriu do réu 14 de dezembro de 2019 (fls. 36/37), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Com efeito, os depoimentos dos policiais foram coesos e harmônicos entre si e respaldados pelo depoimento da testemunha Paul Henrique, que confirmou em juízo ter adquirido drogas do réu. Além disso, em sede policial Eliseu também afirmou que comprou drogas do réu na mesma data dos fatos em análise. Ademais, a prática do tráfico de drogas é corroborada registro de informação anônima de fl. 18, recebido poucos dias antes dos fatos, que relata movimentação de usuários na frente da residência.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela

legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

E não há que se retirar o valor do depoimento das testemunhas policiais em razão de ter um dos agentes da lei narrado um detalhe de um fato de forma distinta de seu colega de farda. A existência de outros ilícitos no mesmo local e o tempo decorrido podem fazer com que o policial não se lembre de detalhes de todas as ocorrências em que houver atuado. Como já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pequenas divergências em testemunhos que versem sobre aspectos tangenciais ao ilícito cuja apuração se dá nos autos não prejudicam a validade da prova:

Apelação das Defesas – Tráfico de drogas – Preliminares de nulidade – Inépcia da denúncia – Rejeição [...] Mérito – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack, além de uma caderneta contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico e determinada quantia em dinheiro – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativas dos acusados isoladas do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinado ao consumo de terceiros – Condenações mantidas [...] Recursos de apelação desprovidos. (TJSP, Apelação proc. 1502221-76.2020.8.26.0228, comarca de São Paulo. 3ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, julgado em 04/11/2020, grifos nossos)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apreensão, após denúncia anônima indicando a casa dos réus e a alcunha da acusada, de 113,40 gramas de “crack”, parte já embalada individualmente e pronta para a venda, e 47,20 gramas de maconha. Palavra dos policiais coerentes e harmônicas, dando conta da apreensão das drogas e de sua venda pelos réus e pelos adolescentes, presenciada durante as campanhas. Pequenas contradições em seus relatos que não têm o condão de desmerecer a prova. Versão dos réus isolada nos autos. Postura de quem se valia da droga para a mercancia ilícita. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Existência de elementos que demonstram o vínculo associativo entre os acusados e os menores para a prática do tráfico.

Caracterização. Condenação dos réus, pelos dois crimes, bem decretada. Penas bem dosadas. Regime fechado adequado. Apelos improvidos. (TJSP Ap. Criminal 0003150-41.2012.8.26.0269. 5ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Pinheiro Franco. Julgado em 25/07/2013, grifos nossos)

Assim, o dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, vendia e trazia consigo as drogas descritas na denúncia, para fins de traficância.

Portanto, o acusado JUNIOR BARAUNA DA SILVA praticou, no dia 13 de dezembro de 2019, o fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/96.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, verifico terem sido apreendidas maconha e cocaína, em pequena quantidade, motivo pelo qual não reconheço a diversidade da droga como negativa, nem sua natureza e quantidade. Por outro lado, considerando a existência de crianças e adolescentes no local onde o réu praticava o tráfico, valoro negativamente as circunstâncias do crime e fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a reconhecer, pois consta na certidão criminal de fls. 329/333 que a condenação nos autos 0000898-50.2016.8.26.0067 foi revertida em segundo grau (desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e extinta a punibilidade pela prescrição), além de as condenações com trânsito em julgado serem por fatos posteriores (1500214-75.2021.8.26.0067 e 1500424-17.2021.8.26.0556).

Na terceira fase, deixo de aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas porque a prova oral produzida dando conta da prática reiterada de tráfico pelo réu e as condenações posteriores por tráfico permitem concluir que ele faz do tráfico seu meio de vida.

Assim, torno definitiva a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que o réu era tecnicamente primário ao tempo do crime.

Em razão da pena aplicada, não há direito a substituição por restritivas de direitos ou ao sursis.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado JUNIOR BARAUNA DA SILVA, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/96, a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

(a) Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

(b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

(c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

(d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

(e) Ofícios de praxe.

Dada a palavra ao Ministério Público e à Defesa, manifestaram intuito de recorrer. Assim, abra-se vista ao Ministério Público para apresentar as razões recursais de apelação no prazo legal. A Defesa sai intimada a apresentar as razões recursais no prazo legal. Com a apresentação das razões por cada parte, abra-se vista ao Ministério Público à Defesa para contrarrazões.

Após, regularizados, observadas as formalidades legais, subam os autos ao E. TJSP com as nossas homenagens.

Publicada em audiência saem as partes presentes intimadas do teor deste termo e da sentença proferida nesta data.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. Esta audiência foi gravada, em sua íntegra, nos termos do Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O arquivo com as gravações foi salvo no Sistema informatizado deste Tribunal, podendo ser acessada no Portal do e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do Comunicado Conjunto CG 1350/2020

Nada mais havendo a ser tratado em referida audiência virtual, lido e estando em conformidade, o(a) MM Juiz(a) deu-a por encerrada, o que foi feito com as cautelas de praxe Nada mais. Eu, , Andre Luiz Salles Maria, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA